

学生A、Bは、不能犯の成否の判断基準に関する次のⅠ、Ⅱの【見解】のいずれかを採って後記【事例】について後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑦までの()内から適切な語句を選んだ場合、後記1から5までのうち誤りを含むものはどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 行為時に一般人が認識し得た事情を基礎とし、一般人を基準に結果発生 of 具体的危険性があるか否かの判断による。
- Ⅱ. 行為時に存在したすべての客観的事情を基礎とし、結果発生 of 具体的危険性があるか否かの判断による。

【事 例】

甲は、健康な乙を毒殺するため、薬品棚から取り出した毒薬のラベルが付いた容器に入った粉を毒薬と認識してその水溶液を乙に多量に注射したが、同粉は、ラベルに表示された毒薬ではなくブドウ糖であったため乙は死亡しなかった。

【会 話】

- A. 私は、甲の罪責については、① (a. 毒薬・b. ブドウ糖) の水溶液を注射する行為が危険であるかどうかを判断し、甲には殺人未遂罪が成立② (c. する・d. しない) と考える。
- B. しかし、A君の見解だと、特定の食物の摂取によりショック死しかねないアレルギー体質を有する乙を、そのことを知った甲が、当該食物を乙に食べさせて殺害しようとした事案で、一般人が乙の体質を認識し得なかった場合には、③ (e. 行為時に存在した全事情を基礎として・f. 行為時に一般人が認識し得た事情を基礎として) 判断することになるから、未遂犯が成立しないこととなり、常識に反する。

- A. そのような場合、私の立場でも、④ (g. 行為時に行為者が特に認識していた事情・h. 事後的に明らかになった全事情) を考慮すべきと考えるので、B君の言う事案でも未遂犯の成立を認めることができる。

それよりも、B君の立場を理論的に徹底すれば、結果が不発生に終わった事案は、ほとんど常に⑤ (i. 不能犯・j. 未遂犯) となってしまうのではないか。

- B. いや、私の立場であっても、事後的・科学的見地から、実際に存在した事実のほか to どのような事実があれば結果が発生し得たかを検討し、そのような事実が行為時に存在し得る可能性の程度を危険判断に取り込むべきと考える。したがって、前記【事例】でも、単に、⑥ (k. ブドウ糖・l. 毒薬) を健康な乙に注射することの危険性を判断するのではなく、毒薬のラベルの付いた容器内にブドウ糖が入っていた原因・経緯なども考慮すべきだ。例えば、その原因・経緯が極めてまれで異常だったという事情は、不能犯を⑦ (m. 肯定・n. 否定) する方向に働くと考ええる。

- ① a、② c
- ③ f
- ④ g、⑤ i
- ⑥ k
- ⑦ m

③ f

③について。まず、Aの第1発言を見た時点では①・②を確定できないので、ひとまず保留する。次にBの第1発言を見ると、③には未遂犯の成立を否定する結論となる記述が入ることがわかる。Bのいう事案の中で一般人は乙の体質を認識し得なかったのであるから、一般人が認識し得た事情を基礎とすると未遂犯は不成立となる。したがって、③にはfが入る。

① a ② c

①・②について。Bの第1発言から、Aの見解は行為時に一般人が認識し得た事情を基礎とすることがわかり、見解Iに立つことがわかる。事例からすると、容器には毒薬のラベルが付いていたのであるから、一般人が認識し得た事情は毒薬の水溶液の注射である。そして、毒薬の水溶液の注射は一般人を基準にすると死の結果発生 of 具体的危険性がある行為であるので殺人未遂罪が成立する。したがって、①にはa、②にはcがそれぞれ入る。

④ g

前述のように、Aは見解Iの具体的危険説に立っている。この見解によると、一般人の立場からの事前判断に加え、妥当な結論を導くために行為者が特に認識していた事情を判断基底に入れることになる。したがって、④にはgが入る。

⑤ i

Bの説（見解II）を徹底すると、行為後の事情まで含めて、事後的に純科学的に考えるべきだという考え方に至る。そしてこのような考え方によると、事後的にみればほとんどの場合、実際に結果が生じなかった理由を見つけ出すことはできるのであり、結果発生 of 具体的危険性はなかったとして、未遂犯は事後的にみればほとんど常に不能犯になりかねない。したがって、⑤にはiが入る。

⑥ k

Bの説（見解II）は客観的事情を基礎とする。そして、本事例では甲はブドウ糖の水溶液を注射したという客観的事情が存在する。したがって、⑥にはkが入る。

⑦ n

Bの第2発言は、実際に存在した事実以外の事実の存在可能性の程度も危険判断の対象にしようというものである。つまり、他の事実の存在可能性によっては未遂犯の成立を認め、不能犯の成立を否定し得る見解である。したがって、⑦にはnが入る。

以上により、() には順に、①=a、②=c、③=f、④=g、⑤=i、⑥=k、⑦=nが入り、したがって、正解は肢5となる。